

## 第26問

暴力団組長である甲とVとの間に、金銭関係のトラブルがあったため、暴力団組員である乙は、甲から「この金で手打ちにしろ。何もしなすめば一番いいが、あいつが嫌がるようなら、こちらをなめられてはいけないから、多少手荒なことはしてもかまわない」と命じられた。乙は、気が進まなかったものの、親分である甲の命令なので、渡された和解金100万円を持参して、仕方なく、V方に交渉に向かった。Vは、乙を見て渋い顔をしていたが、乙を応接間にあげた。

しばらくして、乙が和解金のことを切り出したところ、Vは「貴様、たったそれっぽっちで手打ちにしろと言うのか！わしをなめとるのか！」と怒号しながら、傍らにあった日本刀を引き抜いて、「貴様、叩斬るぞ！」と叫んで、刀を振り回した。はじめは乙も、脅しだろうから、何とかやり過ごそうとしていたが、Vは、途中から、怒りに我を忘れ、乙の左腕に切りつけ、服が破けて血が噴き出した。乙は、このままでは殺されてしまうかもしれないと思って、ドアに向かって逃げようとしていたところ、Vが「貴様逃げるのかぁ」と叫んで、ドアの前で仁王立ちになった。乙も、ここまでされるいわれはないと怒りがこみ上げ、また、甲からの指示も思い出し、側にあった銅製の壺を両手でつかみ、Vの顔面めがけて思い切り投げつけた。Vは壺を避けようとしてよろけ、その際、刀がVの首筋に刺さった。Vは多量に出血をし、すぐ動かなくなり、その後死亡した。

以上の事案における甲及び乙の罪責について論じなさい（特別法違反に言及する必要はない。）。

## 第1 乙の罪責

1 検討する構成要件は傷害致死罪（205）である。殺意まで認定するのは困難だろう。

2 次に、正当防衛（36 I）の成否が問題となる。

乙は、甲から「多少手荒なことはしてもかまわない」と言われており、Vとトラブルになる可能性は認識している。そのため、侵害の予期があると思われるが、侵害の予期があるだけでは、急迫性は失われずと解されている（最判昭46.11.16等）（**論点** 行為者の主観面と急迫性

**論** 司H18,R4,旧H6-1,H14-1）。

また、判例は、防衛の意思と攻撃の意思が併存している場合には防衛の意思が認められるとするから（最判昭46.11.16、最判昭50.11.28【百選 I 24】、最判昭60.9.12）、この程度では防衛の意思は阻却されない（**論点** 防衛の意思 **論** 司H18,H23,旧H6-1,H21-1）。

さらに、Vが怒りに我を忘れて、日本刀を振り回していること、乙は攻撃を回避するためドアに向かって逃げようとしたところVがドアの前に仁王立ちになっていることを考慮すれば、相当性も認められるといつてよいだろう（**論点** 「やむを得ずにした行為」（36 I）（防衛行為の相当性）

**論** 司H18,H23,H27,H29,R4,予H26,旧H21-1）。

総合 62 頁 論証 17 頁

総合 69 頁 論証 20 頁

総合 72 頁 論証 21 頁

## 第2 甲の罪責

1 一応、共謀共同正犯も論点となるが、甲に正犯性が認められることは明らかである（**論点** 共同正犯の成立要件（共謀共同正犯論） **論** H20,H24,H27,H28,H29,R3,予H24,H27,旧H7-1,H14-1,H15-1,H18-1）。ただし、意思連絡がどの時点で認められるのかをきちんと認定しておくべきである。最決平4.6.5【百選 I 90】の第一審は、遅くとも行為者が背後者から説得を受けた時点（話し合った時点）で、未必の殺意による殺人の共謀が成立した旨を認定しているが、原審は、行為者についてはその時点では殺意は認められないとし、行為者が防衛行為に出た時点で背後者との共謀が成立（完成）したと認定している。

2 甲には、侵害の予期があると思われるだけでなく、いわゆる積極的加害意思が認められるから、急迫性を欠く（最決昭52.7.21、なお、最決平29.4.26【百選 I 23】）（**論点** 行為者の主観面と急迫性 **論** 司H18,旧H6-1,H14-1）。

そこで、乙に成立した正当防衛が甲にいかなる効果を及ぼすのか検討する必要がある（**論点** 共同正犯と正当防衛 **論** 司H18,旧H14-1,H21-1）。

この点について、判例（最決平4.6.5【百選 I 90】）は、「共同正犯が成立する場合における過剰防衛の成否は、共同正犯者の各人につきそれぞれその要件を満たすかどうかを検討して決するべきであって、共同正犯者の一人について過剰防衛が成立したとしても、その結果当然に他の共同正犯者についても過剰防衛が成立することになるものではない。」としており、共犯者間の連帯を絶対と解しているわけではない。

ただし、同決定の事案では、本問乙に相当する者（実行者）に成立するのが、正当防衛ではなく過剰防衛であった点には注意が必要である。

総合 139 頁 論証 55 頁

総合 62 頁 論証 17 頁

総合 144 頁 論証 56 頁

## 答案構成

### 第 1 乙の罪責

#### 1 傷害致死罪（205）の成否

↓

#### 2 正当防衛の成否

↓

「不正の侵害」

↓

「急迫」

↓

侵害の予期がある場合であっても、積極的加害意思がない限り「急迫」性は失われない

↓

あてはめ

↓

防衛の意思（「防衛するため」）

↓

防衛の意思と攻撃の意思が併存している場合には、防衛の意思は失われない

↓

あてはめ

↓

「やむを得ずにした行為」

↓

防衛行為の相当性

↓

あてはめ

↓

正当防衛成立

↓

#### 3 乙は不可罰

### 第 2 甲の罪責

#### 1 共謀共同正犯

↓

肯定説

↓

#### 2 共謀成立時点の認定

↓

#### 3 甲は、積極的加害意思があるから、正当防衛は成立しない

↓

共同正犯と正当防衛

↓

違法性は、原則として共同正犯者間で連帯するが、主観的違法要素

は個別化される

↓

あてはめ

↓

4 甲には、傷害致死罪の共同正犯が成立する



## 第1 乙の罪責

1 乙の行為は、Vの「身体を傷害し、よって人を死亡させた」として、  
 2 傷害致死罪（205条）の構成要件に該当する。この点に関して、殺人  
 3 罪（199条）の構成要件に間擬すべきかにも思えるが、銅製の壺を顔  
 4 にめがけて投げつけるという攻撃方法は偶然性に依存する部分が大き  
 5 く、殺人の故意を認めるには足りない。

2(1) 次に、上記乙の行為は、Vが乙を日本刀で切りつけるという「不正  
 6 の侵害」行為に対応してなされたものであり、正当防衛（36条1  
 7 項）の成立が考えられる。

(2)ア 乙は、甲から「多少手荒なことはしてもかまわない」と言われて  
 8 おり、Vとトラブルになる可能性は認識している。そのため、乙に  
 9 は侵害の予期はあると思われるものの、積極的加害意思が認められ  
 10 るなどの事情が無い限り、それのみでは「急迫」性は失われないと  
 11 解すべきである。法は予期された侵害を避けるべき義務を課する趣  
 12 旨ではないからである。甲とは異なり、乙には積極的加害意思まで  
 13 は認められないから、「急迫」性は認められる。

イ また、「防衛するため」といえるためには防衛の意思が必要かが  
 14 問題となるところ、これを欠く行為は社会的に相当とはいえないから  
 15 肯定すべきである。そして、防衛の意思とは、侵害の認識と侵害  
 16 に対応する意思をいい、単に攻撃の意思を併有するのみの場合に  
 17 は、依然として防衛の意思は失われないと解する。防衛行為は事の  
 18 性質上、興奮・逆上して反射的になされることが多いからである。

1

1 本件では、乙はVの攻撃に対して怒りがこみ上げており、攻撃の  
 2 意思を有すると考えられるものの、このままでは殺されてしまうか  
 3 かもしれないと思って反撃に及んでおり、侵害の認識と侵害に対処す  
 4 る意思は有しているといえる。

5 よって、防衛の意思も認められるから、「防衛するため」の要件  
 6 も満たす。

7 ウ 最後に「やむを得ずにした行為」といえるか検討する。

8 「やむを得ずにした行為」とは、防衛行為の相当性を意味する。  
 9 正当防衛の場合、防衛者とその相手方とは「正対不正」の関係にあ  
 10 るから、必ずしも防衛行為が唯一の侵害を回避する方法であること  
 11 は要求されないし、厳格な法益の権衡も要求されないからである。

12 本問では、Vは怒りに我を忘れて、「貴様、叩っ斬るぞ!」と叫  
 13 んで日本刀を振り回しており、すでに乙の左腕に切りつけている。  
 14 また、乙は攻撃を回避するためドアに向かって逃げようとしたところ、  
 15 Vがドアの前に仁王立ちになっており、Vはさらに攻撃の氣勢  
 16 を示しているだけでなく、乙はVの攻撃から逃げることは困難で  
 17 あった。一方、乙の攻撃は、銅製の壺をVの顔めがけて投げつける  
 18 というものであり、凶器の使用法として危険性は低いといえる。

19 以上の事情を総合的に考慮すれば、防衛行為の相当性は認められ  
 20 ると考えられる。

21 したがって、「やむを得ずにした行為」であるといえる。

22 (3) よって、乙には正当防衛が成立する。

2

3 以上から、乙の行為は違法性が阻却されるから、乙は不可罰である。

## 第2 甲の罪責

1 まず、甲は、自ら傷害行為に加わっていないので、「共同して犯罪を  
 実行した」として、傷害致死罪の共同正犯（60条）が成立するかが問  
 題となるが、肯定すべきである。なぜなら、共同正犯において「すべて  
 正犯とする」とされたのは、共同犯行の認識の下、自己の犯罪として当  
 該犯罪を行ったからであるところ、甲は暴力団組長、乙はその配下とい  
 う関係で、乙は甲の指示に服従する関係にあり、甲は自分のトラブルの  
 解決のため乙に指示を出していることから、共同犯行の認識の下、自己  
 の犯罪として行ったものと認められるからである。

2 そして、甲乙間に共同犯行の認識が成立したのは、乙が防衛行為に出  
 た時点である。乙は甲から、Vに対する傷害行為の働き掛けを受け、内  
 心ではこれを受け入れるに至っていないものの、甲の指示に従って、渡  
 された和解金100万円を持参して、V方に向かっており、心理的には  
 甲の働き掛けの影響を強く受けた状態にあり、Vからの攻撃を受けたこ  
 とを契機として、甲からの指示も思い出し、自己を防衛しようとする  
 とともに、ついに甲の共同犯行の働き掛けを全面的に受け入れて共謀を完  
 成させ、これに基づき行為に出たものと認められるからである。

したがって、甲は、傷害致死罪の共同正犯の構成要件に該当する。

3 一方で、甲には、乙の行為について、正当防衛は成立しない。

甲は、乙に対して、「多少手荒なことをしてもかまわない」と告げて  
 おり、当初から和解の機会を利用してVを加害する意思を有していたと

3

思われる。そのため、甲には、侵害の予期だけでなく、積極的加害意思  
 が認められるところ、上記の通り、このような場合には「急迫」性の要  
 件が欠けるからである。

そうすると、共同正犯者間で違法性阻却事由の有無が異なることとな  
 るが、このような場合、一方に成立した違法性阻却事由が他方に影響を  
 及ぼすか。

共同正犯も他人の行為を通じて間接的に法益侵害を生じさせていると  
 いう面を否定できないから、共犯従属性の議論は共同正犯においても排  
 除する理はない。そして、共犯従属性においては制限従属性説が妥当と  
 考える。共犯は正犯を通じて間接的に法益侵害を行う点に処罰根拠があ  
 るため、共犯の可罰性を認めるには、正犯者が違法な行為をなしたこと  
 を要し、かつ、それで足りるというべきであるからである。

以上を前提とすると、正当防衛は違法性阻却事由であるから、原則的  
 に共同正犯者間で連帯する。

もっとも、共同正犯のうち一人に積極的加害意思があるような場合は  
 別に考え得る。このような主観的事情は行為無価値的な違法要素である  
 と考えることができ、そのような違法要素は連帯しないと解すべきだか  
 らである。

本件では、上記の通り、甲と乙では積極的加害意思という主観的事情  
 が異なるから、乙に成立した正当防衛が甲に影響を及ぼすことはない。

4 以上から、甲には傷害致死罪の共同正犯（205条、60条）が成立  
 する。

以上

4